

1501978-62.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... detalhando a função de cada um deles no tráfico.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo e do STJ:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501978-62.2021.8.26.0628 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501978-62.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277397/2021 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 20760017 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3444/21/406 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2277397 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAILTON DA CONCEIÇÃO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JAILTON DA CONCEIÇÃO, WESLEY DA CRUZ SILVA e YNARA SANTOS DA SILVA, já qualificados nos autos, como incurso no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia (fl. 174-176):

No dia 09 de outubro de 2021, por volta das 19h00min, Rua Onofra da Silva Crispim, nº08, Crispim, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, os denunciados, agindo em concurso e com unidade desígnios, guardavam e traziam consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar, 02 porções de maconha, com peso líquido de 1,8g, 21 porções de crack, com peso líquido de 2,8g, 39 porções de cocaína, com peso líquido de 55g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, além de R\$ 389,00 em dinheiro trocado, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudo de constatação de fls.30/32.

Os réus foram citados e apresentaram defesa prévia, sendo designada audiência de instrução e julgamento.

Nesta oportunidade, o representante do Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal aos denunciados Wesley e Ynara, que aceitaram a proposta, conforme termo anexo, razão pela qual foi suspenso o processo em relação a eles.

Por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores em relação ao réu Jailton, o parquet deixou de oferecer a ele a proposta, prosseguindo o processo. Assim, foi reafirmado o recebimento da denúncia, ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu.

Ao fim, o Ministério Público pediu a procedência da ação nos termos da denúncia, com reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase, reincidência na segunda, e afastamento do art. 33, §4º por reincidência, fixando-se o regime inicial fechado.

A defesa, por sua vez, pediu absolvição por falta de provas, alegando que não foram vistos atos de mercancia e que a declaração de Ynara ficou isolada, assim como a dos policiais, não se comprovando a prática de nenhuma das condutas do caput do 33. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o 28. E, na dosimetria, alegou não haver reincidência específica, pois o réu nunca respondeu por tráfico.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Assim dispõe o artigo 33 da Lei n. 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5-9), auto de exibição e apreensão (fls. 10), autos de constatação de substância entorpecente de fls. 30-32 e laudos periciais de fls. 238-240 que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A testemunha Geraldo Cruz Junior, em juízo, disse que estava em patrulhamento quando viu três indivíduos em uma viela, e, no momento em que perceberam a polícia, Wesley mudou o rumo para onde iria, e Jailton jogou uma sacola no chão. Por tais motivos, foi feita a abordagem e na busca pessoal encontraram, na sacola que Jailton havia soltado, os entorpecentes. Ynara teria informado aos policiais que eles estavam realizando o tráfico ali, sendo Jailton responsável pela venda, Wesley o campana do local, e ela responsável pela guarda do dinheiro. Questionada, Ynara disse que o dinheiro estava guardado em sua calcinha e entregou aos policiais, que conduziram todos até a delegacia. Ynara teria dito que fazia pouco tempo que trabalhava no local, assim como Wesley, mas Jailton havia dito que estaria lá há mais tempo. Contou que o local em que os investigados foram abordados já houve algumas prisões por tráfico. Jailton não era conhecido dos policiais. Não visualizou atos de mercancia.

A testemunha Maurício Soares de Lima disse que sua equipe se encontrava em

patrulhamento quando os três réus saíram de uma viela, sendo que um deles fez menção de correr, razão pela qual a equipe fez a abordagem. O réu Jailton era procurado da justiça. A ré Ynara contou que Jailton era responsável pela venda de drogas, sendo ela responsável por guardar o dinheiro e Wesley era o olheiro. Que o réu, ao tentar fugir, soltou uma sacola na qual estavam os entorpecentes apreendidos. Contou que o réu Jailton tentou negar, inclusive negou que estava procurado, mas que Ynara contou que ele era o responsável pelo tráfico.

Em seu interrogatório, o réu Jailton disse que as acusações são falsas. Contou que estava em casa, assistindo o jogo Corinthians x Sport, mas seu irmão o chamou para ir comprar drogas em uma boca, quando encontraram uma viatura de policiais que os abordou. Que Ynara e Wesley já estavam abordados, sendo o réu deitado no chão ao lado de uma sacola de drogas que os policiais disseram que era dele. Disse ser falsa a versão apresentada pelos policiais. Não conhece Ynara, e Wesley apenas de vista, não sabendo o porquê da versão por eles apresentada na delegacia.

Assim, embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Ademais, como se sabe, o depoimento dos policiais não possui presunção de veracidade absoluta, porém, quando coeso com o restante da prova, não havendo qualquer circunstância a lhe desautorizar deve ser levado em consideração.

E é justamente esse o caso em análise, afinal, toda a narrativa dos policiais, repetida de maneira coesa na fase inquisitorial e sob o manto do contraditório, vai ao encontro do que foi relatado pela denunciada Ynara, que em solo policial (fl. 11), confirmou que estava no local com Wesley e Jailton, detalhando a função de cada um deles no tráfico.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo e do STJ:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Bis in idem - Inexistência - Regime prisional fechado - Cabimento - Recurso da Defesa improvido com o acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1500492-93.2019.8.26.0569; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

Importante ainda destacar que o tráfico de drogas não se consuma apenas com o ato típico de "venda". Se o acusado pratica qualquer uma das 18 condutas descritas nos "verbos" ou "núcleos" do art. 33 da Lei 11.343/06 terá incorrido no crime, inclusive na hipótese de apenas "guardar" ou "ter consigo" a droga.

Por isso, também não se exige um elemento subjetivo especial, ou seja, a demonstração da intenção específica de praticar atos de mercância. Basta o dolo genérico, a consciência e vontade de realizar alguma das ações que configuram o crime e dispensam a venda.

Em relação à alegação de que o réu seria mero usuário de entorpecentes, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, contempla alguns parâmetros para se determinar se a droga se destinava ao uso pessoal do agente. Destarte, dispõe o dispositivo em comento que para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, entendo que a diversidade de droga apreendida (cocaína, maconha e crack) acondicionadas em mais de 60 porções individuais, somada com o relato da corré Ynara e dos policiais, é suficiente para afastar a tese de desclassificação par ao art. 28 da Lei 11.343/06.

Logo, está bem caracterizado o crime de tráfico de drogas, afinal, a prova colhida nos autos é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal e material. Sua conduta foi ilícita, o réu era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena (art. 68, CP).

Primeira fase da dosimetria.

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, combinado com art. 42, da Lei de Drogas, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, não sendo possível tal valoração; o motivo do crime é inerente ao tipo em questão; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, mas serão utilizadas na terceira fase da dosimetria. As consequências, embora gravosas, são inerentes ao tipo penal e, por fim, não há que se falar em comportamento da vítima ante a natureza do crime.

O réu ostenta 6 condenações definitivas com trânsito em julgado anterior aos fatos ora tratados, nenhuma delas atingida pelo período depurador (0000636-36.2015.8.26.0617, 0058817-92.2009.8.26.0050, 0015544-48.2018.8.26.0050, 0023781-76.2017.8.26.0577, 0026468-60.2016.8.26.0577, 0026795-73.2014.8.26.0577).

Assim, reconheço os maus antecedentes do réu, e, no intuito de evitar o bis in idem, utilizarei a primeira das condenações (0000636-36.2015.8.26.0617) para o reconhecimento e aplicação da agravante de reincidência na segunda fase, e as cinco condenações remanescentes para majorar a pena base no presente momento.

Nesse sentido:

Apelação. Furto. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada (em 1/4), unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de cinco condenações definitivas (uma delas já atingida pelo período depurador) que permite o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STJ. Na segunda fase, também de rigor a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime inicial equivocado que não comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1501535-59.2019.8.26.0571; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020)

Diante a esses aspectos, considerando a existência de circunstância judicial

desfavorável, no caso, os maus antecedentes do réu, e considerando tratarem-se de diversas condenações, fixo a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Segunda fase da dosimetria.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante do art. 61, inc. I, do CP, uma vez que o réu é reincidente (0000636-36.2015.8.26.0617).

Não estão presentes circunstâncias atenuantes da pena.

Assim, majoro a pena em 1/6, perfazendo nesta fase um total de 7 anos e 700 dias-multa.

Terceira fase da dosimetria.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Anoto que, não obstante o réu não seja reincidente específico no crime de tráfico, o fato de possuir contra si diversas condenações por outros crimes já é o suficiente para impedir a aplicação da benesse legal.

Neste sentido:

TRÁFICO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Confissão policial e judicial do réu – Depoimentos de agentes policiais – Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Análise que se faz em cada caso concreto – Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório – Desclassificação inadmissível – Condenação mantida – Básica majorada em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (282,69g de cocaína) – Condenação anterior por tráfico privilegiado – Reincidência não específica – Confissão e menoridade – Uma atenuante que autoriza reduzir a pena ao mínimo legal e outra atenuante compensada com a reincidência – Pena reduzida – Reincidência, todavia, que impede a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas – Regime fechado mantido – Recurso parcialmente provido (voto n. 40616).

(TJSP; Apelação Criminal 1500359-80.2019.8.26.0624; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)

Regime inicial de cumprimento.

Sendo o réu reincidente e em razão do montante de pena, o regime é, necessariamente, o fechado. Além disso, a reincidência e os maus antecedentes constituem valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo após sancionado diversas vezes, desta forma, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial fechado.

A reincidência também impede a aplicação do redutor, a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR JAILTON DA CONCEIÇÃO à pena de reclusão, pelo prazo de 7 anos, em regime inicial fechado, bem como a 700 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, em virtude da conduta típica descrita no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao

Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Todavia, por serem inservíveis e antieconômicos para a SENAD, determino a destruição dos bens.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, sobretudo pelas diversas condenações recentes, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

Neste sentido:

"3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes." STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de prisão e todo o necessário para o cumprimento da pena.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA